Signature Not Verified
Assinado por MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES em 27/07/2010 16:11:16.249 GMT-03:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FRANQUIAS POSTAIS DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.615.555/0001-64, com sede na Rua Helena Piekarski Pinto, n.º 674, Fazenda Velha, Araucária – Paraná, CEP 83704-650, por seus advogados adiante firmados, estabelecidos com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, apresentar:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE c/c preceito cominatório de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM CARATER CAUTELAR

Em face da Inconstitucionalidade que se opera no Decreto 6.639 de 07 de novembro de 2008 que regulamenta a Lei 11.668 de 02 de maio de 2008, sendo necessária a impugnação do artigo 2° §3° inc. I, artigo 4°, artigo 5° e artigo 9° §§ 1° e 2°, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

O advogado, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes, inscrito na OAB-PR 31.367, que abaixo subscreve, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei que os documentos ora juntados são fotocópia fidedigna dos documentos originais, bem como, as fotocópias digitais da Lei 11.668/2008 e do Decreto 6.639/2008 foram extraídas on line, do sitio do Senado Federal – Portal legislação - texto atualizado, respondendo este advogado cível e criminalmente por quaisquer documentos, ora juntados que não se tratem de fotocópia fidedigna daqueles que foram anexados com a inicial.

Curitiba, 26 de julho de 2010.

_____
Marcelo Arthur Menegassi Fernandes
OAB-PR 31.367

I) PRELIMINARMENTE

I – a) DA PERTINENCIA TEMÁTICA

Trata-se a presente ADIn de discussão acerca da inconstitucionalidade do Decreto 6.639/2008 que regulamenta a Lei 11.668/2008, Lei de Franquia Postal, fato este de interesse da autora que representa seus associados, e dos mais de 1400 franqueados em todo o país, todos franqueados no seguimento postal.

Todos os associados são denominados de ACF, ou seja, Agencia de Correio Franqueado e em sua grande maioria mantém com a ECT relação jurídica há mais de 17 anos.

A Lei 11.668/2008, em seu art. 6°, inc. III e IV determina que:

"Art. 6° – São objetivos da contratação da franquia postal:

*III – **a manutenção e expansão** da rede de Agencia dos Correios Franqueadas, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;*

IV – a melhoria do atendimento prestado à população".

A Lei determina que a rede de Agencia de Correios Franqueadas – ACF seja mantida e expandida, bem como o atendimento prestado seja melhorado.

O Decreto 6.639/2008, ora impugnado, ao invés de regulamentar a Lei 11.668/2008, simplesmente cria um novo modelo, sem qualquer estudo de viabilidade econômico - financeiro, ou seja, a AGF e determina que a relação jurídica existente, ACF x ECT, seja extinta, violando gravemente não apenas a Constituição Federal, a Legalidade dos princípios que norteiam a formação de um Decreto, mas sobretudo o direito dos associados, quais sejam as ACF – Agencias dos Correios Franqueadas.

Violam assim **preceitos fundamentais**, como o principio da legalidade, o direito à livre iniciativa e o princípio do livre exercício do trabalho, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, transformando assim a própria Lei 11.668/2008 em um **ato normativo inconstitucional**.

Não bastasse a agressão constatada, coloca-se em risco um serviço público essencial, pois manda licitar na modalidade concorrência, sem qualquer parâmetro mínimo de treinamento ou de estudo econômico-financeiro, não podendo assim prever como inclusive dito pela própria ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, as conseqüências desta licitação, cuja mesma já se encontra novamente frustrada, não conseguindo fugir à **teoria da dupla crise**, da **teoria da efetivação da melhor contratação** e da **teoria da co-autoria**, já que se trata do segundo edital lançado em menos de 12 meses e quase 76% das concorrências atuais estão suspensas JUDICIALMENTE.

Não obstante, é de se constatar por esta Excelsa Corte que a Lei de Franquia Postal, determina a regularização dos contratos de franquia, mas em momento algum determina que esta regularização seja através da licitação na modalidade concorrência.

A lei de Franquia Postal aponta para a formalização do ato administrativo através da contratação direta, adjudicação

direta, fato este que se verifica quando a própria Lei fica subsidiada a Lei 8.666/1993 e em hipótese alguma fica subsidiada às leis 9.074/1995 e 9.648/1998, ou seja, o presente contrato de franquia postal esta submetido a regra prevista no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e não à regra contida no art. 175 da Constituição Federal.

Atenta-se ao fato de que falar-se de adjudicação direta e/ou contratação direta não se trata de perpetuação destas franquias no poder, até porque a formalidade do ato que está previsto no art. 116 e demais regras da Lei 8.666/1993 requer as mesmas exigências, todavia sem o processo de licitação na modalidade concorrência, não causando qualquer desequilíbrio, seja para quem detêm o Know How há 17 anos, seja para quem não tem nenhuma experiência.

Oportuno ainda destacar que a Lei 11.668/2008 em momento algum igualou o contrato de franquia postal às concessões ou permissões e como já amplamente decido pelo Superior Tribunal de Justiça o contrato de franquia é contrato atípico, de conteúdo próprio e a ele não se enquadra, tampouco se assemelha o contrato de prestação de serviço, dos quais se prevê a licitação sob a forma de concessão e/ou permissão.

Considerando que o Decreto, ora impugnado extingue a modalidade de franquia que existe atualmente no país e da qual os associados fazem parte, considerando que o Decreto extingue a relação jurídica entre as ACFs e a ECT e portanto fere o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos associados, considerando que o Decreto impõe a data limite de operação das franquias de correio, ou seja as ACF, qual seja, a data de 07 de novembro de 2010, sendo que após esta data todas devem ser fechadas, comprovado está a pertinência temática entre o interesse da autora e seus associados e o objeto da presente ADIn.

I – b) DA LEGITIMIDADE ATIVA

Trata-se a autora de uma associação de caráter nacional que reúne pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade, qual seja, a de franquia postal.

Conforme pode se verificar no artigo 2° do Estatuto, Primeira Alteração, consta como prerrogativas da autora:

"Parágrafo Primeiro: Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um regimento interno aprovado pela Assembléia Geral;

Parágrafo segundo: A esta associação nacional poderão se filiar associação de outros estados e municípios, cujos membros que as compõe sejam pessoas jurídicas cuja atividade esteja relacionada com o serviço de franquia postal, bem como, toda e qualquer pessoa jurídica cuja atividade tenha por objetivo o serviço de franquia postal;

Parágrafo terceiro: Esta associação poderá defender os direitos inerentes a sua classe e subclasse em âmbito nacional, conforme regra prevista no art. 103, inc. IX da Constituição Federal".

A autora esta composta de pessoas jurídicas de uma mesma classe, que por sua vez desempenham a mesma atividade, qual seja, a atividade de franquia postal e estão submetidas ao mesmo tipo de contrato, bem como, vinculadas juridicamente a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Existe no caso visto em tela a **conexão** dos objetivos comuns dos associados que por sua vez comungam de um mesmo interesse, tornando-os assim homogêneos em face do objeto final, pois pretendem alcançar o mesmo sucesso, a mesma justiça, a mesma igualdade e a mesma legalidade, que por ora, esbarra na inconstitucionalidade do Decreto 6.639/2008, ora impugnado.

Ainda em vista da regra insculpida no **art. 5°, inc. LIV da Constituição Federal**, tratado como principio fundamental, do qual derivam todos os outros princípios, tem-se que o principio do devido processo legal é a garantia do exercício da justiça, do direito de ação, que incentiva a legitimidade da autora na busca do objeto ora pretendido.

Conforme entendimento desta Excelsa Corte, consta no mandato em anexo, os poderes especiais e específicos outorgados para a finalidade supramencionada.

I – c) DA LEGITIMIDADE ATIVA INDEPENDENTEMENTE DA REPRESENTATIVIDADE EM NOVE OU MAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO OBJETO AQUI PRETENDIDO

O entendimento desta Excelsa Corte determina que para que uma associação seja reconhecida como sendo de caráter nacional e, por conseguinte tenha legitimidade para propor uma ADIn deve ter representatividade em nove ou mais Estados da Federação.

Tal entendimento, que tem como fundamento a Lei Orgânica para constituição dos partidos políticos, passou a ser utilizado de forma generalizada em aproveitamento a toda e qualquer associação de âmbito nacional tendo por objetivo limitar a participação das associações frente ao que reza a regra do art. 103 de nossa Carta Magna sob o prisma de que se tal associação não tem representatividade nacional, também não pode alcançar em tese, os interesses da sociedade como um todo.

Todavia, toda limitação severa, via de conseqüência, com o tempo passa a se **potencializar**, a ponto de interferir no direito constitucional do cidadão, da sociedade, deixando assim de avaliar as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso visto em tela, a presente associação não tem representatividade em nove ou mais Estados da Federação, tem representatividade apenas nos estados do Paraná e de Santa Catarina, mas busca, através da tutela jurisdicional do Estado, junto a esta Excelsa Corte um bem jurídico que assiste a mais de 1400 franqueados em todo país, ou seja, não esta representada em nove estados, mas representa o interesse de franqueados estabelecidos em 23 Estados e o Distrito Federal, afora o interesse social, já que se trata de serviço essencial público.

No que pese não ter como associados estes mais de 1400 franqueados, a impugnação de um Decreto falível, representa a correção e a alteração de um dos processos licitatórios mais inviáveis e irregulares que o país já presenciou em nível nacional.

No que pese não ter como associados estes mais de 1400 franqueados, o objeto jurídico aqui pretendido visa evitar que uma relação jurídica seja continuada ou construída em meio a uma legislação que fere princípios e direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Federal.

Importante neste mesmo norte estabelecer que nem a Constituição Federal, nem qualquer Lei Ordinária determina que uma associação nacional tenha em seu corpo de associados pessoas estabelecidas em nove ou mais estados da Federação.

Da mesma forma a presunção análoga de que esta representatividade se opere frente à permanência de um representante em cada estado, num total de nove, não lhe dá a condição de pessoa jurídica, associação, que potencialmente poderia representar os interesses de uma coletividade, da sociedade.

Necessário então que a avaliação desta representatividade ocorra de forma menos superficial, ou seja, não apenas no **plano físico, espacial**, da existência de um representante em cada estado, mas sim de forma mais aprofundada, verificando o conteúdo do pedido e as conseqüências do mesmo em relação a todos que se encontram sediados pelos Estados da Federação.

Veja, esta Excelsa Corte, que no caso em apreço, temos medidas judiciais em todo o país, promovida por sindicatos estaduais e pelos próprios franqueados, impugnando o edital de licitação por irregularidades e por inexigibilidade de se licitar na modalidade concorrência.

Conforme demonstra o quadro sinóptico abaixo é possível verificar o resultado destas demandas até o presente momento:

Importante aqui verificar que muitas ações individuais não estão contabilizadas, o que por certo eleva o número de demandas e resultados consideravelmente.

QUADRO SINOPTICO REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICAIS QUE DISCUTEM O EDITAL DE LICITAÇÃO DAS AGF

ESTADO	Nº DE AÇÕES	AÇÕES			Nº CONCORRENCIAS	SITUAÇÃO DAS AÇÕES
		DEFERIDAS	INDEFERIDAS	SEM JULGAMENTO		
AC	**00**	-	-	-	03	Não houve ação judicial.

AL	**03**	00	03	00	14	Nenhuma ação deferida.
AM	**01**	00	00	01	02	Nenhuma ação deferida.
BA	**24**	04	18	02	35	Suspensão de 04 Concorrências.
CE	**03**	02	00	01	09	Suspensão de 08 Concorrências.
DF	**03**	01	01	01	11	Suspensão de TODAS as Concorrências.
ES	**21**	07	12	02	23	Suspensão de 07 Concorrências.
GO/TO	**03**	01	02	00	35	Suspensão de 01 Concorrência.
MG	**07**	02	02	01	146	Suspensão de TODAS as Concorrências.
MS	**00**	-	-	-	04	Não houve ação judicial.
MT	**01**	00	01	00	15	Nenhuma ação deferida.
PA/AP	**10**	00	02	08	24	Nenhuma ação deferida.
PB	**03**	01	01	01	12	Suspensão de TODAS as Concorrências.
PE	**03**	01	01	01	18	Suspensão de TODAS as Concorrências.
PI	**01**	01	00	00	08	Suspensão da assinatura de TODOS os contratos até julgamento final do MS.
PR	**01**	01	00	00	82	Suspensão de TODAS as Concorrências.
RJ	**31**	03	11	17	60	Suspensão de 03 Concorrências.
RN	**02**	00	02	00	12	Nenhuma ação deferida.
RO	**00**	-	-	-	08	Não houve ação judicial.
RS	**17**	01	10	06	86	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SC	**13**	03	05	04	24	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SE	**01**	01	00	00	09	Suspensão de TODAS as Concorrências
SP	**80**	37	08	35	301	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SPI	**01**	01	00	00	123	Suspensão de TODAS as Concorrências
TOTAL	**229**	**67**	**79**	**80**	**941**	**Suspensão de 720 Concorrências.**

• 76,51 % DAS CONCORRÊNCIAS ESTÃO SUSPENSAS, EM VIRTUDE DAS LIMINARES DEFERIDAS.

Por certo haverá mais algumas milhares de ações propostas por aqueles que perderem esta licitação acusando que a mesma esta fundada em um Decreto Inconstitucional, o que provocaria um caus

jurídico maior do que foi implantado atualmente, prejudicando não apenas o franqueado e a ECT, mas principalmente o serviço postal e os cofres públicos.

Quando se tem por objetivo comprovar a inconstitucionalidade do Decreto, visando a suspensão da licitação em todo o país e conseqüente suspensão do prazo que extingue em novembro de 2010 os contratos atualmente vigentes, através de cautelar, não se tem apenas o objetivo de favorecer ao interesse pessoal dos associados, pois trata-se de assunto de interesse coletivo que atinge a todos os franqueados, bem como atinge a sociedade.

Noutro vértice, ao afastar a legitimidade de uma associação, sem antes verificar a profundidade e relevância do tema que a mesma visa defender é o mesmo que violar as regras insculpidas no art. 5°, inc. XVII e XVIII, bem como a regra contida no art. 174 §2° de nossa Constituição Federal.

Assim define a regra contida no art. 174 §2° da Constituição Federal:

> ***"§2° - A Lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo".***

Por analogia é possível firmar entendimento no sentido de que tal regra não visa apenas o desenvolvimento econômico de uma associação, mas estrutural, social, e se assim o é, por certo não lhe possibilita mediante todas as dificuldades que existem para que se forme uma associação, que esta venha emergir sem incentivos e estímulos.

O que ocorre quando de pronto se julga extinta uma ADI sem julgamento do mérito sob a razão de que a associação não esta representada em nove estados, permitindo que tal fato seja tratado como requisito legal para propositura de uma ação de interesse nacional, é o mesmo que desestimular e deixar de incentivar confrontando assim a regra supracitada.

Não obstante, se é **plena** a **liberdade** de uma associação para fins lícitos e a criação destas não podem sofrer interferência estatal em seu funcionamento conforme reza a regra contida nos incisos XVII e XVIII do art. 5° de nossa Carta Magna, quando se restringe o alcance de sua legitimidade por conta de uma "representatividade", o que se faz na

verdade é ferir a liberdade plena e ainda provocar a interferência do Estado, enquanto poder máximo judiciário – STF no funcionamento e regulamento de cada associação.

Vale aqui lembrar que tal regra foi idealizada a partir de um modelo de regulamento referente aos partidos políticos, de forma análoga e a partir de então foi generalizada, aplicando-se a toda e qualquer associação independente do propósito e alcance do objeto da ação.

Em tese ao se deparar com a violação das regras supracitadas, também tem-se que o **principio do devido processo legal** foi maculado pois sobretudo se está compelindo o direito à justiça, o direito de ação.

Importante ainda com fulcro na regra do **art. 5°, inc. LIV da Constituição Federal**, que ao determinar que uma associação não tem legitimidade para determinada e única ação, é tratar com iniqüidade tal questão, e, desta forma estaria se ferindo outro principio, o principio da isonomia, da igualdade.

Neste sentido, ou uma associação de caráter nacional tem legitimidade para propor as ações que lhes determina a legislação, pois formada para defender interesses de seus associados em âmbito nacional ou não tem legitimidade alguma.

A própria regra contida no art. 103, inciso IX da Constituição Federal foi devidamente regulamentada pela Lei 9.868/1999 que traz na regra contida em seu art. 2° inciso IX a possibilidade e legitimidade de uma associação de caráter nacional propor uma ADI.

Daí o risco de se presumir analogamente que a regra prevista na lei orgânica dos partidos políticos possa ser base para todas as demais associações existentes em nosso país.

Via de regra, a lei orgânica estabelece a representatividade em nove ou mais Estados Federados do país para partidos políticos como forma de legitimá-los como partido político e não para proporem Ação judicial.

Não obstante, a própria lei orgânica dos partidos políticos assegura na regra contida no artigo 3° da Lei 9.096/1995 sua plena liberdade como preceito fundamental contido na Constituição.

Trata-se o presente objeto jurídico tutelado de interesse coletivo num primeiro momento, um direito coletivo que não apenas pode assistir a classe à qual esta associação esta vinculada mas também atinge a terceiros que ainda não são franquias de correio, ficando assim vinculado até mesmo a um **interesse difuso**.

Conforme definição do ilustre Ministro, ex-presidente do STF, Gilmar Ferreira Mendes em sua obra acerca do tema, tem-se que:

> *"Relativamente à legitimidade das "entidades de classe de âmbito nacional" e das "confederações sindicais**", é difícil admitir a juridicidade da exigência quanto à representação da entidade em pelo menos nove Estados da Federação**, como resultado decorrente da aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos".*
>
> *Ainda que se possa reclamar a fixação de um critério preciso sobre tais conceitos vagos – entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical -, **não há duvida de que eles devem ser fixados pelo legislador e não pelo Tribunal**, no exercício de sua atividade jurisdicional. O **recurso à analogia** aqui é de **duvidosa exatidão**".(ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, EDITORA SARAIVA, 2009 1 EDIÇÃO, MENDES, GILMAR FERREIRA, PG. 99).Grifo Nosso.*

Desta forma, **data máxima vênia**, o peso que tem a decisão desta Excelsa Corte como norte para o desenrolar dos embates jurídicos, estas decisões não podem e não devem suplantar preceitos fundamentais, não apenas tocantes a legitimidade como ora se aborda, mas também em razão dos preceitos fundamentais violados pelo próprio Decreto impugnado.

Por outro lado, inadvertido seria determinar a ilegitimidade de uma associação de caráter nacional em face de uma determinada "representatividade física", como se esta representatividade não fosse mutável, como se à esta associação no curso do processo não pudessem se afiliar outros franqueados de todo o país.

O tratamento que tem se dado ao presente tema deve ser revisto, para assim, poder a presente ADI ser analisada e os preceitos

fundamentais aqui ditos violados serem defendidos por esta Excela Corte como bem opinou os eminentes juristas Celso Ribeiro bastos e Aléxis Galiás de Souza Vargas, quando do julgamento da ADPF:

> *"(...) Com isso, o Excelso Pretório cumpre o seu papel primordial de guardião-mor da Constituição e da ordem jurídica, bem como faz uma ponte entre o controle concentrado e o difuso, uma vez que sua decisão incidirá diretamente sobre os diversos processos judiciais...". Há que se decidir univocamente sobre o tema magno, sob pena de ser atropelada a segurança jurídica e o Estado de Direito, que ficam seriamente prejudicados diante do dissenso acerca dos seus pilares de sustentação, que são os preceitos fundamentais da Lei Maior".*(PRECEITO FUNDAMENTAL E A AVOCATÓRIA, *IN SUPLEMENTO* DIREITO E JUSTIÇA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE DE 26.06.2000).

Com todo o respeito, faço das palavras dos eméritos juristas, supracitados, minhas palavras para concordar e dizer que se cabe ao Excelso Pretório o papel de guardião-mor da Constituição, necessário que nenhuma presunção análoga, como esta que ora se discute, exceda aos preceitos fundamentais, dos quais o Supremo Tribunal Federal, deve firmá-los contra a imperícia jurídica do ato normativo que origina a inconstitucionalidade.

Trata-se portanto a presente associação de verdadeira entidade de classe, que visa defender e representar os interesses inerentes à atividade desenvolvida por seus associados, qual seja, a de franquia postal.

II) DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade decorre da violação do Decreto 6.639/2008 em razão de suas funções, extrapolado-as, pois cria e ao mesmo tempo extingue direitos, conseqüentemente gera obrigações que não estavam presentes na Lei regulamentada, dando-lhe por certo outra interpretação e assim tornando-a inconstitucional.

Ao regulamentar a Lei 11.668/2008, alterando-a, discrepando da finalidade para a qual a lei foi criada, o decreto não apenas

deixou de regulamentá-la, como tratou de matéria não prevista na Lei 11.668/2008, bem como, quando de suas alterações, violou outras regras constitucionais, proveniente do direito fundamental, tão bem salvaguardado por nossa Carta Magna.

Considerando tratar-se de violação que se afere fundamentalmente no âmbito do direito constitucional, no que pese beirar a ilegalidade, inadmissível que tal matéria seja discutida à distância, fora do alcance da guarda e vigília daquele à quem compete e está legitimado a orientar o bem maior de um país, neste caso o Supremo Tribunal Federal e como ferramenta se faz necessário a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Quando o Decreto, que ora se impugna, tratou de modificar a Lei 11.668/2008, provocou um verdadeiro descompasso no que até hoje, pôde ser intitulado de o caso de maior sucesso no *franchise* nacional, qual seja, a criação da Agencia de Correio Franqueada - ACF.

Descompasso, porque, conforme se comprovará, manda licitar, o que não é possível licitar na modalidade concorrência, criando uma nova denominação – AGF - sem sequer possuir, existir ou determinar, qualquer estudo de viabilidade econômico – financeiro, em seguida porque fere as normas e os princípios constitucionais, pois determina que tal contrato esta subsidiado a determinadas Leis, inclusive a de licitação, o que implica em adjudicação direta, já que está vinculado àquelas normas de forma indireta e por fim, extingue um ato jurídico prefeito e não reconhece o direito adquirido, que nada mais é do que a relação jurídica existente entre as mais de 1400 franquias de correios espalhadas pelo país e a ECT, que em sua grande maioria prevaleceu por mais de 17 anos, ferindo inclusive o **principio à livre iniciativa** e o **livre exercício do trabalho**.

Necessário deixar bem claro e transparente que a presente discussão não enseja a **perpetuação** de nenhuma franquia postal a frente de tal atividade, mas tão somente ver cumprida integralmente sua função **sócio-política-jurídica**, até porque, a própria licitação em andamento no país, decorrente do Decreto 6.639/2008 em questão é a maior prova de que a licitação foi frustrada, na qual ora havia apenas um concorrente, ora sequer havia concorrente.

Não obstante, em resposta a pergunta que se deve fazer: por qual motivo não se deu simplesmente continuidade a licitação se nem concorrente havia? Pelo fato de que nenhum direito se conquista através de

atos que são considerados inconstitucionais, pois mesmo que representem um resultado instantâneo positivo, nada o justifica a ponto de se conseguir mantê-lo.

Não se trata mais de um país, no qual, as questões, que muitas vezes produziam efeitos apolíticos, antijurídicos e ilegais se resolviam de forma desautorizada e marginalizada, portanto necessário a apreciação da presente ADIn, seu acolhimento e por fim, após esvaziado todas as discussões acerca do tema, seu deferimento.

III) DO TEXTO DO DECRETO 6.639/2008 IMPUGNADO

A seguir fica exposto o texto que se pretende impugnar, considerando que os mesmos agridem e violam preceitos fundamentais em nossa Constituição.

> *"§ 3° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se:*
>
> *I - Agência de Correios Franqueada - AGF: pessoa jurídica de direito privado, selecionada em procedimento licitatório específico e contratada pela ECT para o desempenho da atividade de franquia postal;"*
>
> *"Art. 4° A ECT instaurará procedimento licitatório visando à contratação de pessoa jurídica de direito privado, interessada em desempenhar atividades auxiliares relativas ao serviço postal, observadas as disposições da Lei nº 11.668, de 2008, e deste Decreto".*
>
> *"Art. 5° A operação da AGF se dará, exclusivamente, mediante a celebração de contrato de franquia, firmado entre a ECT e a pessoa jurídica selecionada em procedimento licitatório, na modalidade concorrência, utilizando o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995".*

Viola aqui o **principio da legalidade**, pois extrapola sua finalidade de poder regulamentador, criando um novo modelo de franquia, que sequer é citado na Lei 11.668/2008, sem qualquer estudo de viabilidade econômico-financeira.

Fere o principio **à livre iniciativa e o princípio do livre exercício do trabalho,** uma vez que põe fim a uma classe que existe a mais de 18 anos, ao contrário do que determina a lei.

Ainda, deixa de cumprir com o que determina o **principio da igualdade**, uma vez que, jamais uma empresa com 18 anos de Know How irá concorrer com equidade, com uma empresa que nunca atuou neste ramo de atividade e vice e versa, sempre havendo perda por conta do processo seletivo equivocado demandado do Decreto, ora impugnado.

> *"Art. 9° A ECT terá o prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da data da publicação deste Decreto, para concluir todas as contratações previstas no art. 7o da Lei no 11.668, de 2008, observadas as disposições deste Decreto.*
>
> *§ 1° Na data em que as AGFs contratadas mediante procedimento licitatório iniciarem suas operações, extinguir-se-ão, de pleno direito, os contratos firmados pela ECT com as Agências de Correios Franqueadas, a que se refere o caput do art. 7º da Lei nº 11.668, de 2008, cujas instalações se encontrem nas áreas de atuação das primeiras.*
>
> *§ 2° Após o prazo fixado no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 11.668, de 2008, serão considerados extintos, de pleno direito, todos os contratos firmados sem prévio procedimento licitatório pela ECT com as Agências de Correios Franqueadas. (Redação dada pelo Decreto nº 6.805, de 2009)".*

Viola o principio contido no art. 5°, inciso ***"XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;"***, ou seja, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Ainda determina o prazo final da relação jurídica existente, ou seja, determina quando a relação jurídica entabulada entre as partes deve se encerrar, sem que as partes demonstrem o ânimo para assim proceder.

IV) DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Tal pretensão tem como fundamento jurídico a regra contida no art. 5° inc. XIII, XXXV e XXXVI; art. 8°; art. 37; art. 102 inc. I a); art. 102 §1°; 103 inc. IX da Constituição Federal, art. 273 §7° do Código de Processo Civil, Lei 9.868/1999 e demais legislações pertinentes ao caso visto em tela.

V) DO PEDIDO CAUTELAR CONFORME REGRA PREVISTA NO ARTIGO 10° E SEGUINTES DA LEI 9.868/1999

Passa-se a expor os fundamentos que demonstram a necessidade do deferimento da medida cautelar, cujo objetivo é afastar o perigo iminente que sofre os franqueados em face da fumaça do bom direito e do perigo da demora que ora se apresenta.

Não basta neste tópico, apresentarmos os pontos inconstitucionais que em tese entende-se haver, já que estamos apenas iniciando a fase de conhecimento do processo, necessário que acima de tudo, em sede de cognição sumária o Emérito Ministro entenda que exista vestígios daquilo que se reivindica, principalmente na fase preliminar.

Necessário acima de tudo que seja demonstrado os danos decorrentes do ato normativo considerado inconstitucional.

Em citação ao mestre Marinoni, o Prof. Antonio Claudio da Costa Machado assim se manifesta:

> *"Tem razão, portanto, Luiz Guilherme Marinoni quando assevera que, "a cognição sumária é uma cognição menos aprofundada em sentido vertical... própria das situações de aparência, ou melhor, dos juízos de probabilidade", arrematando, em seguida, que se trata, "da cognição pertinente aos procedimentos que não permitem, em razão de uma determinada situação, a cognição aprofundada do objeto litigioso" e que é "característica da tutela cautelar e da tutela sumária antecipatória".*

Por conseguinte, como se trata de inconstitucionalidade de preceito fundamental, cuja interpretação e aplicação em nossa Carta Magna é rígida nas relações em que tais regras se operam as conseqüências do ato normativo impugnado geram de pronto a construção de uma relação jurídica, ou seja, de um contrato administrativo deficiente e juridicamente incorreto, bem como, determina a extinção da relação jurídica atual entre franqueado e franqueador.

Nestes dois momentos, seja no momento que se extingue a relação, seja no momento em que se dá início a uma nova relação, ambos são atos viciados, antijurídicos e por certo com futuro curto e incerto.

Tem-se no presente processo judicial que visa auxiliar o controle da constitucionalidade três pontos que em decorrência do perigo da demora e da fumaça do bom direito, merecem ser apreciados e deferidos em caráter cautelar e concedidos com efeito *ex tunc*.

- A necessidade de suspensão do edital de licitação em nível nacional ou pelo menos dos editais dos associados, já que se trata de edital com mesmo objeto e cuja origem vem em decorrência da determinação do Decreto 6.639/2008 – **cuja finalidade é evitar que se de continuidade e/ou início a uma relação jurídica deficiente e juridicamente incorreta**;

- A suspensão da eficácia da norma contida no inc. I §3° do art. 2°, art. 4° e art. 5° do Decreto 6.639/2008 – **cuja finalidade é evitar que se instaure outro procedimento licitatório equivocado e embasado em norma inconstitucional**;

- A suspensão da eficácia da norma contida no art. 9° §§ 1° e 2° que determina o prazo final para a atual relação jurídica entre as Agencias de Correio Franqueadas e a Empresa Brasileira de Correios, que ocorrerá em 11 novembro de 2010 – **tendo em vista que a Lei não pode extinguir um ato jurídico perfeito, tampouco ferir o direito**

adquirido e ainda o principio a livre iniciativa e o livre exercício do trabalho;

A medida de urgência ora requerida, se faz necessária visto a presença da verossimilhança das alegações presentes nesta ADI, uma vez que, uma licitação não pode ocorrer quando decorre de um ato normativo inconstitucional, que violou os princípios da legalidade, da livre iniciativa e do livre exercício do trabalho, todos preceitos fundamentais.

No mesmo diapasão não pode o prazo a que faz menção o parágrafo 2° do artigo 9° do Decreto 6.639/2008 continuar vigente, já que fere o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e ainda determina a data final de uma relação jurídica, todos preceitos fundamentais.

Tanto em um momento quanto em outro a presença de violação de preceitos fundamentais, possibilita que a presente cautelar, em sede de cognição sumária, seja alcançada, pois da simples análise superficial impossível infirmar que a licitação e a extinção dos contratos vigentes ocorre em meio a um ato normativo inconstitucional.

Sendo assim, ante as provas incontestes carreadas aos autos, requer seja deferida a medida de urgência, a fim de que seja suspenso **EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE AGF POR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, SOB O REGIME DE FRANQUIA POSTAL**, bem como, **SUSPENSO O PRAZO, DATADO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA A EXTINÇÃO DOS ATUAIS CONTRATOS DE FRANQUIA, ACF x ECT CONTIDO NO §2° DO ART. 9° DO DECRETO 6.639/2008**, uma vez presentes o "*fumus boni juris*" comprovados através da verossimilhança das alegações e documentos juntados e o "*periculum in mora*", cuja finalidade é evitar prejuízos e danos irreversíveis aos franqueados, a ECT e a terceiros, bem como, aos cofres públicos e a própria sociedade, afora a necessidade de garantir a segurança jurídica e o Estado de Direito.

Ainda com o objetivo de evitar que o preceito não seja cumprido, requer, desde já, seja aplicado uma multa diária, a ser arbitrado Pelo Emérito Ministro, conforme previsto na regra do art. 461 do Código de Processo Civil, sob pena de também se considerar descumprimento de ordem judicial:

> ***Art. 461 – "Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado equivalente ao do adimplemento.***
>
> ***...§ 5º - Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requerimento de força policial".***

Necessário a suspensão da licitação, bem como, do prazo referendado à extinção dos contratos, até que exaurido toda e qualquer discussão acerca da inconstitucionalidade do Decreto, sob pena de qualquer relação jurídica proveniente deste procedimento licitatório estar abrigado sob um ato normativo inconstitucional.

VI – DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI 11.668/2008 E DA ADJUDICAÇÃO DIRETA – CONTRATAÇÃO DIRETA COMO FORMA CORRETA DE SE LICITAR

A Lei 11.668/2008 esta **vinculada de forma direta** a regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978, que nada mais é do que a possibilidade de contratar através de contratos como o de franquia ou convênios atendendo as conveniências técnicas, ou seja:

> *"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.*
>
> *§ 3º - A empresa exploradora dos serviços, atendendo a **conveniências técnicas** e econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades, **pode celebrar contratos e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços**, mediante autorização do Ministério das Comunicações".*

A Lei 11.668/2008 esta **vinculada de forma indireta** a outras leis, conforme determina a regra contida no art. 3°, que assim estabelece:

> Art. 3° - *"Os contratos de franquia postal celebrados pela ECT são regidos por esta Lei e, **subsidiariamente**, pelas leis n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e 8.666, de 21 de junho de 1993, utilizando-se o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995".*

Quando uma lei esta subsidiada a outras, é porque esta lei esta orientada, **vinculada de forma indireta** a tais leis, portanto não se submetendo à sua atividade jurídica de forma plena.

Veja Eméritos Ministros, até o presente momento tem-se que a Lei 11.668/2008 é a lei que regula a atividade de franquia postal no país, todavia, a mesma lei esta fincada nos preceitos estabelecidos pela Lei 6.538/1978 e subsidiada à outras leis, quais sejam, Lei 10.406/2002; Lei 8.955/1994; Lei 8.666/1993.

Veja que ainda deve utilizar como **critério de julgamento** àquele previsto no **inciso IV** da regra contida no art. 15 da Lei 8.987/1995, qual seja, melhor proposta técnica com preço fixado no edital.

Por qual motivo, a lei determina que seja seguida a regra prevista no inciso IV do caput do art. 15 e não aquela do caput do art. 15 do inc. IV, porque conforme adiante ficará demonstrado e comprovado, o contrato de franquia, não se trata de contrato de prestação de serviço normal, corriqueiro, tampouco de contrato comercial, já que tem causa e conteúdo próprios, conforme assevera o nosso Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Atenta-se aqui ao fato que a Lei 11.668/2008 não manda licitar na modalidade concorrência, determina que se utilize o critério de julgamento contido no inciso IV do art. 15, até porque a Lei 8.987/1995 faz alusão à licitação de contratos de prestação de serviços em decorrência de **permissão e concessão**, o que não se aplica a um contrato de franquia, ou seja:

"Art. 1° - As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos".

Ora, Eméritos Ministros, a própria legislação em vigor responde a nossa pergunta, ou seja, a Lei 9.648/1998 assim alterou a Lei 9.074/1995:

"VII – os serviços postais.

Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT com as Agencias de Correios Franqueadas – ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações ***que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão****, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro de 2002".*

Incluiu os serviços postais, autorizando que tais serviços também poderiam ser contratados mediante concessão e/ou permissão, mas em hipótese alguma fez-se entender que o contrato de franquia era um contrato fruto da permissão ou da concessão, não equivalendo-os.

Veja que a Lei 11.668/2008 revoga este parágrafo, ou seja, elimina a hipótese de que tais contratos seriam provenientes da concessão ou permissão, uma vez que sequer fica subsidiada à Lei 9.074/1995.

Noutro vértice, a Lei 11.668/2008, em momento algum determina que os contratos de franquia postal, sejam os antigos, sejam os novos, tenham que ser licitados na modalidade concorrência, tampouco determina a criação de uma nova denominação para este tipo de contrato, já que faz alusão a Agencia de Correio Franqueado, ou seja, as ACFs, em seu art. 7°.

Importante aqui esclarecer que o critério de julgamento pode ser utilizado tanto para a contratação direta, quanto para a contratação via licitação na modalidade concorrência, pois ambos exigem ato formal.

A prova irrefutável de que não se pretendia mudar a denominação dada às franquias, bem como, não se pretendia licitar na modalidade concorrência outro modelo de franquia, ou seja, AGF, é o conteúdo da regra do art. 6°, inc. III e IV que assim determina:

> *"III – a **manutenção** e expansão da rede de **Agencia dos Correios Franqueadas**, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;*
>
> *IV – a **melhoria do atendimento prestado à população**".*

Veja Eméritos Ministros, que, se a pretensão é de se manter o que já existe, impossível que tais contratos sejam licitados da forma como propõe o Decreto, pois provenientes de uma relação jurídica nascida justamente da regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978, que trata de contratos vinculados a contratação direta, adjudicação direta e que não são provenientes de uma licitação antecedente.

Ainda, se visa à melhoria no atendimento à população, por certo que jamais permitiria que fosse aberto um certame sem a presença da regra contida no art. 27 da Lei 8.666/1993, qual seja, sem a presença da habilitação – qualificação técnica.

Por fim, na regra contida no art. 7°, verifica-se que o que se determina de fato era a regularização dos contratos até então vigentes, todavia, como visto acima, não seria plausível regulá-los via meio licitatório na modalidade concorrência, possibilitou-se a regularização via meio licitatório mediante contratação direta submetendo de forma indireta o contrato de franquia postal, contrato atípico, às regras de determinadas leis, dentre as quais a de licitação.

A aplicação subsidiária da Lei 8.666/1993, bem como, o critério de julgamento supracitado, à Lei 11.668/2008, nada mais é do que a aplicação do conceito de contratação direta, como ocorre nos casos de convênios, acordo ou outros tipos de contratos, contratos estes específicos, exclusivos, como o de franquia postal.

Assim entende o Ilustre mestre Wellington Pacheco Barros:

> *"O contrato administrativo, segundo o parágrafo único do art. 2° da lei 8.666/1993, é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares envolvendo um acordo de vontades para o fim de formação de vínculo com a estipulação de obrigações recíprocas. Pelo dispositivo legal, claramente se observa que o contrato administrativo se formaliza tendo a Administração Pública e os particulares como contratantes.*
>
> *Dessa forma,* ***não se aplica*** *a lei 8.666/1993 de forma vinculante e obrigatória aos contratos firmados entre a Administração e particulares, como os convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra forma contratual.* ***A aplicação é meramente subsidiária****. Questão lógica é a de que não se aplica a estes contratos a licitação apenas o que for pertinente a parte contratual".* (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ED. ATLAS, BARROS, WELLINGTON PACHECO, 2009, PG 268)

É tão evidente a condição de contratação direta que a lei determina para o contrato de franquia postal que apenas que se faça constar, obrigatoriamente, determinadas cláusulas e condições, constantes do art. 4° da Lei 11.668/2008, que praticamente repetem as condições estabelecidas na regra do art. 55 da lei 8.666/1993.

Ainda conforme a regra contida no art. 116 da Lei 8.666/1993, tem-se que:

> *Art. 116. "Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e* ***outros instrumentos congêneres celebrados*** *por órgãos e entidades da Administração".*

Pois bem, Eméritos Ministros, logo no início a Lei 11.668/2008 assim define no §1°, do art. 1°:

"Sem prejuízo de suas atribuições, responsabilidades e da ampliação de sua rede própria, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ***poderá utilizar o instituto da franquia*** *de que trata o caput deste artigo para desempenhar* ***atividades auxiliares relativas ao serviço postal***, ***observado o disposto no §3° do art. 2° da Lei 6.538 de 22 de junho de 1978****".*

O §3° do art. 2° da Lei 6.538 de 22 de junho de 1978 assim determina:

"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.

§ 3º - A empresa exploradora dos serviços, atendendo a conveniências técnicas e econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades, ***pode celebrar contratos e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços****, mediante autorização do Ministério das Comunicações".*

A celebração de contratos e convênios nada mais é do que a possibilidade da adjudicação direta nesta contratação, cuja mesma base orientou a contratação dos contratos atualmente em vigor e que trata-se de um ato formal vinculado o processo administrativo.

Portanto, o preceito constitucional ao qual esta submetido a presente relação jurídica não é o da regra contida no art. 175 da Constituição Federal, mas sim o da regra contida no artigo 37 inc. XXI da Constituição Federal.

Assim determina o art. 37, inciso XXI de nossa Carta Magna:

"XXI - ***ressalvados os casos especificados na legislação****, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure* ***igualdade de condições*** *a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,* ***mantidas as condições efetivas da***

> ***<u>proposta</u>***, ***<u>nos termos da lei</u>***, *o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".*

O presente artigo, regulado pela Lei 8.666/1993, quando interpretado deixa evidente que existe logo no início a consideração as ressalvas que por ventura possam existir em nossa legislação, determinando ainda que a igualdade de condições seja respeitada e mantida as condições de acordo com a Lei.

No que pese, em tese, se defender que o contrato regido pela Lei 11.668/2008 esta submetido à regra contida no art. 37, inc. XXI, e não ao art. 175 da Constituição, o Decreto, ora impugnado, não respeita em momento algum o conteúdo que se exprime do inciso XXI supramencionado.

Ora, Excelsa Corte, o Decreto 6.639/2008 não respeita os termos da Lei 11.668/2008, alterando-a, criando uma nova modalidade, enquanto a Lei pretendia e objetivava a manutenção e expansão do modelo já existente, determina que haja licitação para este novo modelo e na modalidade concorrência, momento no qual jamais conseguiria chegar a condições de igualdade entre os atuais franqueados e terceiros interessados que não detém experiência alguma e por fim não trataram da Lei 11.668/2008 como um contrato administrativo, previsto como exceção, que é proveniente de uma legislação própria e que se enquadra na ressalva inicial do inciso citado.

Outrossim, passa-se a expor e impugnar as regras contidas no Decreto 6.639/2008, por serem inconstitucionais, bem como, por terem alterado e excedido os preceitos e regras contidas na Lei 11.668/2008, bem como, suas obrigações, gerando uma verdadeira confusão jurídica.

VII) A IMPUGNAÇÃO AS REGRAS CONTIDAS NO DECRETO 6.639/2008 EM FACE DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE

O Decreto em seu art. 2° mantém em sua íntegra a redação dada ao art. 1° §1° da Lei 11.668/2008, que a vincula de forma direta a Lei 6.538/1978.

Todavia, logo no inciso I do §3° do mesmo artigo extrapola criando um novo modelo – AGF -, da qual a Lei 11.668/2008 não criou, tampouco previu, já que quando fez menção em todo o tempo a Agencia de Correios Franqueada, fez menção aquelas que já existiam e pretendia que fossem mantidas, art. 6° inc. III, quais sejam: ACF – Agencia de Correio Franqueada.

Ainda, o inciso I do §3° do art. 2° determina que este novo modelo – AGF – seja licitado na modalidade concorrência.

Em momento algum a Lei 11.668/2008, determinou a criação de um novo modelo para as franquias de correio, sempre fazendo menção as Agencias de Correio Franqueada, ACF.

Prova irrefutável deste argumento é encontrada na própria regra do art. 9° §1° do Decreto, qual seja – *"Na data em que as AGFs contratadas mediante procedimento licitatório iniciarem suas operações, extinguir-se-ão, de pleno direito, os contratos firmados pela* ***ECT com as Agencias de Correios Franqueadas***, ***a que se refere o Caput do art. 7° da Lei 11.668/2008****, cujas instalações se encontrem nas áreas de atuação das primeiras".*

Em todo o tempo a Lei 11.668/2008 sempre fez menção as Agencias de Correios Franqueadas - ACF, portanto a nova denominação criada pelo Decreto - AGF, bem como a exigência de se licitar deturpou, extrapolou e modificou o objetivo da Lei, qual seja, a manutenção e regularização dos contratos existentes, prevista na regra contida no art. 6° da Lei de Franquia Postal.

Ao concluir esta idéia, tem-se por lógico que a Lei 11.668/2008 nunca determinou que o contrato de franquia postal fosse licitado na modalidade concorrência, tampouco que os contratos de franquias existentes, onde consta ACF e ECT, da mesma forma o fossem, pois juridicamente impossível.

O que se delimitou, foi que tais contratos fossem regularizados, bem como, os que viessem em decorrência da necessidade de expansão fossem frutos da formalidade exigida pela relação havida entre a Administração Pública e a pessoa jurídica de direito privado, todavia via o ato formal da **contratação direta/adjudicação direta**.

Reforçando a inconstitucionalidade do art. 2° §3° inc. I do Decreto 6.639/2008 e de forma totalmente incoerente e contrária ao que a Lei 11.668/2008 estabelece, passa a viger o art. 4° e art. 5° do Decreto 6.639/2008, com uma curiosidade contida no art. 5°, que abaixo se descreve:

> *"Art. 5° - A operação da AGF se dará, exclusivamente, mediante a celebração de contrato de franquia, firmado entre a ECT e a pessoa jurídica selecionada em procedimento licitatório, na modalidade concorrência, utilizando o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995".*

Atenta-se ao fato, que não bastasse à criação de um novo modelo – AGF – os artigos supracitados agora mencionam que a seleção ocorrerá em procedimento licitatório na modalidade concorrência.

Ora Eméritos Ministros, a Lei 11.668/2008, não determinou que nenhuma agência de correio franqueada fosse licitada na modalidade concorrência, tampouco criou outra denominação sendo certo que tanto para a contratação direta, quanto para a contratação via licitação na modalidade concorrência se exige a mesma formalidade, pois trata-se de ato administrativo formal.

Até aqui, poderia se dizer que o que ocorre é uma ilegalidade, todavia, a criação de um novo modelo – AGF - não prevista na Lei, através de uma nova forma de contratação – licitação na modalidade concorrência - extrapola, o principio da legalidade, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito daqueles contratos já existentes, já que no art. 9° em ambos os parágrafos, ou existe a substituição ou existe a extinção dos contratos anteriores.

Antes de adentrarmos nesta fase da inconstitucionalidade do Decreto importante firmar que a Lei 11.668/2008 determina que os contratos antigos devem ser substituídos mediante sua regularização frente a regras contidas na Lei de Franquia Postal e não **extintos** ou **eliminados**.

Já o objetivo do Decreto que era apenas regulamentar, na realidade criou um novo modelo de franquia, sem qualquer base ou estudo, desprovido de qualquer embasamento lógico jurídico, sequer econômico financeiro, descumprindo o que determinava a Lei 11.668/2008 quanto a

regularização dos contratos e sua manutenção, mas ao contrário determinando a substituição e sua extinção.

Ora Emérito Ministro trata-se de um Decreto ou de uma Lei, e se Lei o fosse também constitucional não seria, visto que extingue o ato jurídico perfeito fruto do direito adquirido, fugindo de suas funções e por tal motivo violou preceitos constitucionais.

Assim depreende-se dos comentários de Nelson Nery Junior acerca do tema:

> *"A edição do decreto tem a lei como seu fundamento de validade, de sorte que encontra limitação da lei regulamentada* ***e não pode criar nem extinguir direitos e obrigações não constantes da lei regulamentada****. Em seu poder regulamentar, o Presidente – e demais chefes do poder executivo estadual, municipal e distrital – age, exclusivamente e indelegavelmente, apenas e somente secundum legem, sendo-lhe vedado agir praeter ou contra legem(Stassinopoulos. Traité, §10, I, p. 69). O decreto regulamentar será inconstitucional se tratar de matéria não prevista em lei (STF, Pleno, ADIn 1435-8-DF, rel. Min. Francisco Rezek)*".(CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL, 2 EDIÇÃO, JUNIOR, NELSON NERY, ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS, PAG. 446/447).

O §1° do art. 9° do mesmo Decreto define que somente serão extintos:

> *"§1° - Na data em que as AGFs contratadas mediante procedimento licitatório iniciarem suas operações, extinguir-se-ão, de pleno direito, os contratos firmados pela ECT com as Agencias de Correios Franqueadas, a que se refere o Caput do art. 7° da Lei 11.668/2008,* ***cujas instalações se encontrem nas áreas de atuação das primeiras****".*

> Ou seja, o art. 7° da Lei 11.668/2008 assim determina:

> *"Até que entrem em vigor os contratos de franquia postal celebrados* ***de acordo com o estabelecido nesta lei****, continuarão com eficácia aqueles firmados com as Agencias de Correios Franqueadas que estiverem em vigor em 27 de novembro de 2007".*

Quanto ao §2° do art. 9° do Decreto 6.639/2008, é contraditório ao próprio entendimento do conteúdo do §1°, bem como se contrapõe ao que estabelece a própria Lei 11.668/2008 em seu art. 1° e 3°.

No mesmo norte, passemos a analisar a regra contida no inciso IV do art. 15 da Lei 8.987/1995, à qual a Lei 11.668/2008 também esta subsidiada, qual seja:

> *"...*
>
> *IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital";*

Veja Eméritos Ministros, o legislador em hipótese alguma diz que a Lei 11.668/2008 esta subsidiada ao caput do art. 15, mas tão somente ao inciso IV.

A Lei 11.668/2008 determina que o **critério de julgamento** seja o previsto no inciso IV do caput do art. 15 e não que a contratação seja realizada através de licitação conforme o caput do art. 15 e o inciso IV.

Pois bem, veja o que delimita em sua obra Marçal Justen Filho acerca da contratação direta:

> *"...Essa flexibilidade não foi adornada de discricionariedade. O próprio legislador determinou as hipótese em que se aplicam os procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação administrativa. O administrador será obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais.* ***Permanece o dever de realizar a***

> ***melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes***.
>
> *Portanto,* ***a contratação direta não significa eliminação de dois postulados consagrados a propósito da licitação. O primeiro é a existência de um procedimento administrativo. O segundo é a vinculação estatal `a realização de suas funções"***. (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 295)

Desta forma, fica evidente, o motivo que levou a Lei 11.668/2008 a compilar determinadas leis, dando como parâmetro a forma, ou seja**, o ato formal** que deveria ser praticado, seguido pela **Administração Pública quando da contratação direta, adjudicação direta,** qual seja, pela regra do inciso IV do caput art. 15 da Lei 8.987/1995.

Ainda em citação ao mesmo autor:

> *"A contratação direta submete-se a um procedimento administrativo, como regra. Ou seja, ausência de licitação* ***não equivale*** *a* ***contratação informal****, realizada com quem a administração bem entender, sem cautelas nem documentação. Ao contrário, a contratação direta exige* ***um procedimento prévio****, em que a observância de* ***etapas e formalidades é imprescindível***.
>
> *A diferença residirá em que, no momento de definir as fórmulas para contratação, a Administração constatará a inaplicabilidade das regras acerca de licitação"*. (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 296).

É possível assim entender que para a contratação direta, ou seja, para a adjudicação direta, o que se pretende é avaliar e produzir a melhor proposta possível e nada melhor para isso do que ter como parâmetro melhor proposta técnica com preço fixado no edital, já que se

esta falando de um serviço essencial público e cuja especialidade não é corriqueira, tampouco cabe a qualquer um seu exercício.

No mesmo diapasão, não é possível admitir que o contrato de franquia, seja o contrato de franquia atual, seja o contato de franquia postal, trate-se de uma concessão de prestação de serviço público, conforme determina a regra contida no art. 175 da Constituição Federal:

> *"Art. 175 – Incumbe ao poder público na forma da lei, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos":*

Veja Eméritos Ministros, que o contrato de franquia não possui características de um contrato de prestação de serviços, como bem definiu o STJ em recentes decisões:

"RECURSO ESPECIAL Nº 873.440 - RS (2006/0169502-8) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : FLORES CARLESSO E CARLESSO LTDA ADVOGADO : RICARDO MELLO BOSCHI RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PROCURADOR : PAULO RUY RODRIGUES LEAL E OUTRO(S) EMENTA TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA FRANQUEADA QUE PRESTA SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. DECRETO-LEI 406/68 E LC 56/87 VIGENTES À ÉPOCA. PERÍODO ANTERIOR À LC 116/03. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Os serviços prestados por empresas franqueadas que realizaram atividades postais e telemáticas, sob a égide da LC 56/87, não são tributados pelo ISS. (Precedentes:REsp 783125 / RS , 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 29/08/2006 RESP 403.799-MG, DJ de 26.04.2004, Rel. Min. Franciulli Netto; RESP 189.225-RJ, DJ de 03.06.2002, Rel. Min. Peçanha Martins). 2. A edição da LC 116/03, que entrou em vigor a partir de 01/01/2004, enunciou, no item 26.01 de sua lista anexa, como hipótese de incidência do ISS, os "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas". Destarte, a partir de então, ressoa indubitável a incidência da exação sobre os serviços postais e telemáticos realizados pelas agências franqueadas dos Correios. 3. Sob esse enfoque, é cediço no STJ que a LC 116/03 somente entrou em vigor a partir de 01/01/2004, não atingindo, portanto, o período sub judice, qual seja, de 1997 a 2002. 4. Deveras, a aferição da natureza do contrato, em face da sua atipicidade, demanda revolvimento do contexto fático-probatório, porquanto enseja a análise apurada de suas cláusulas, providência

inviável no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 05/STJ, consoante já assentado pela C. 1ª Turma. (Precedente: AGRESP 442225 / PR, PRIMEIRA TURMA, DJ 30.08.2004) 5. In casu, conquanto o acórdão recorrido tenha esposado entendimento contrário ao desta Corte Superior, no sentido de que ""(...) seja antes ou após a LC 116/03, não há falar em inexistência de relação jurídica tributária, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos da inicial era medida que se impunha", o juízo monocrático, com ampla cognição fático probatória, ***asserindo a natureza de franquia relativa ao contrato em tela, assim se manifestou, in verbis****: "Cotejando, assim, a definição legal da espécie contratual e aquilo que de fato contrataram as partes, não há como negar que realmente se está diante de pacto de franquia empresarial, porquanto presentes, na definição, todos os requisitos a tanto legalmente instituídos.(...) Como ressaltado, a definição do objeto e das tarefas contratuais dão conta de que a franqueada* ***exerceria as atividades sob a marca dos correios****, formalizando ACF (agência de correio franqueada),* ***e distribuindo****, em nome próprio, os serviços prestados* ***originalmente por aquele****, cobrando as respectivas tarifas e repassando ao franqueador a remuneração ajustada pela cessão da marca. Não me parece, portanto, que a atividade descrita se enquadre na definição do art. 1º da Lei 4.886/65, regente da representação comercial e de cujos termos, a seguir transcritos, já se pode de pronto verificar a inconfundível diversidade entre as referidas práticas.(...)E se assim é, forçoso reconhecer que as rendas decorrentes dos estritos serviços advindos daquela contratação não estão sujeitos à tributação pelo ISSQN, porquanto não incluídos na lista anexa à Lei Complementar 56/87 tampouco no rol do art. 10 da LC Municipal 01/02 (fls. 68/89), sendo certo, além disso, que, ante o inafastável princípio da legalidade tributária, referido elenco não pode admitir qualquer espécie de interpretação extensiva.(...)Relativamente à venda de títulos de capitalização levada a efeito pela Autora - que, inclusive, assim reconheceu na inicial -, mais especificamente no que tange à comercialização da chamada "telesena" (fl. 90), contudo, deve prosperar o entendimento defensivo. Em primeiro lugar, porque esta espécie de serviço não consta dentre aqueles exclusivamente cedidos pela EBCT em função da franquia (postais e telemáticos); e também, porque esta atividade se enquadra, é inegável, no item 61 do art. 10 da LC nº 01/02. O mesmo se diga em relação ao serviço de fotocópias (xerox) igualmente prestado pela Autora (fl. 191), não abrangidos pela imunidade tributária, algo que observo apenas para constar, já que a isenção quanto a este sequer foi postulada nesta ação." (fls. 233/237) 6. Recurso Especial provido, para*

determinar a não-incidência do ISS sobre os serviços prestados exclusivamente em função do contrato de franquia celebrado com a EBCT, anteriores a 01/01/2004, data em que entrou em vigor a LC 116/03".

*"Processo AgRg nos EDcl no REsp 786861 / DFAGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2005/0168210-0 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/12/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2009 Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISSQN. FRANQUIA. FATO GERADOR POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 116/03 (ITEM 26.01 DO ANEXO). INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A situação tributária das franquias no que tange à exigência de ISSQN deve ser apreciada sob dois enfoques. 2. Na vigência da Lei Complementar n. 56/87, tinha-se verdadeira hipótese de não-incidência, **já que os contratos de franquia, por terem causa e conteúdo próprios (Lei n. 8.955/94), não se confundiam com os contratos de prestação de serviços** (esses sim figurantes do rol trazido por aquele diploma normativo, que deu nova redação ao anexo do Decreto-lei n. 406/68). Precedente. 3. Com a edição da Lei Complementar n. 116/03 - que entrou em vigor apenas em 1.1.2004 -, as franchising, de forma geral, foram expressamente incluídas na lista de serviços que tornam exigível o tributo (item 10.04 do anexo daquela lei complementar). As franquias relacionadas à prestação de serviços postais ganharam regulamentação no item 26.01. Precedente. 4. Na ausência de declaração de inconstitucionalidade desses últimos dispositivos, permanecem eles válidos e produzindo efeitos. 5. Agravo regimental não-provido".*

***"AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 953.840 -RJ (2007/0115791-3) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. FRANQUIA (FRANCHISING).NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA (PLEXO INDISSOCIÁVEL DE OBRIGAÇÕES DE DAR, DE FAZER E DE NÃO FAZER). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCEITO PRESSUPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO QUE EXTRAVASA O ÂMBITO DA VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA INFIRMAR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.** *O ISS na sua configuração constitucional incide sobre uma*

prestação de serviço, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad substantia obligatio in faciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar. Outrossim, a Constituição utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio, com que implícita a norma do artigo 110, do CTN, que interdita a alteração da categorização dos institutos. Consectariamente, qualificar como serviço a atividade que não ostenta essa categoria jurídica implica em violação bifronte ao preceito constitucional, porquanto o texto maior a utiliza não só no sentido próprio, como também o faz para o fim de repartição tributária-constitucional (RE 116121/SP). Sob esse enfoque, é impositiva a regra do artigo 156, III, da Constituição Federal de 1988, verbis : "Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...)" A dicção constitucional, como evidente, não autoriza que a lei complementar inclua no seu bojo atividade que não represente serviço e, a fortiori , obrigação de fazer, porque a isso corresponderia franquear a modificação de competência tributária por lei complementar, com violação do pacto federativo, inalterável sequer pelo poder constituinte, posto blindado por cláusula pétrea. O conceito pressuposto pela Constituição Federal de serviço e de obrigação de fazer corresponde aquele emprestado pela teoria geral do direito, segundo o qual o objeto da prestação é uma conduta do obrigado, que em nada se assemelha ao dare, cujo antecedente necessário é o repasse a outrem de um bem preexistente, a qualquer título, consoante a homogeneidade da doutrina nacional e alienígena, quer de Direito Privado, quer de Direito Público. Deveras, o Código Tributário Nacional, como de sabença recepcionado como lei complementar, tratava dos Impostos sobre Serviços de Qualquer natureza, em seus artigos 71 a 73, revogados pelo Decreto-Lei nº 406/68, que estabeleceu normas gerais de Direito Financeiro, aplicáveis ao ICMS e ao ISS. Consoante o aludido decreto-lei, constituía fato gerador do ISS a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista anexa ao diploma legal, ainda que sua prestação envolvesse o fornecimento de mercadoria. Na citada lista de Serviços, anexa ao Decreto-Lei 406/68, com a redação dada pela Lei Complementar 56, de 15 de dezembro de 1987, encontrava-se elencada a atividade de "Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);" (Item 48). Destarte, a franquia não era listada como serviço pelo legislador complementar, mas, sim, as atividades de corretagem, agenciamento e intermediação que a tivessem por objeto, panorama que restou modificado pela Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que revogou os artigos 8º, 10, 11 e 12, do Decreto-Lei 406/68, bem como a Lei Complementar 56/87, entre outros dispositivos legais. Os Itens 10 e 17, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, elencam, como serviços tributáveis pelo ISS, o

agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de leasing , de franchising e de factoring (Subitem 10.04), bem como a franquia (Subitem 17.08). ***A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto, composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço (obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios.*** *(...)" Os fundamentos de índole notadamente constitucional, sem as quais não sobreviveria o aresto recorrido, impõem timbrar seu núcleo constitucional para, na forma da jurisprudência cediça na Corte, não conhecer do recurso especial (Precedentes do STJ:* ***REsp 912.036/RS****, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 08.10.2007;* ***AgRg no Ag 757416/SC****, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 03.08.2006;* ***AgRg no Ag 748334/SP****, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 30.06.2006;* ***REsp 754545/RS****, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 13.03.2006;* ***AgRg no REsp 778173/MG****, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 06.02.2006; e* ***AgRg no REsp 658392/DF****, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 21.03.2005).* ***VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):*** *A decisão agravada ostenta o seguinte teor: (...) Com efeito, cinge-se a controvérsia à incidência ou não de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN sobre a atividade de franquia (franchising). Prima facie, impende inquirir do critério material integrante da regra-matriz de incidência tributária do ISS, a fim de explicitar o comportamento humano abstratamente descrito na hipótese normativa e que, no dizer de Amílcar Falcão, representa 'fato econômico de relevância jurídica'. (...) Carlos Maximilian ensina que se deve afastar as interpretações impossíveis ou ilógicas: pois, é da mais gritante falta de lógica, tanto comum, como jurídica, a interpretação que pretende conferir a esse preceito o significado de conferir à lei complementar o definir "serviços de qualquer natureza", para efeito de abrir espaço à competência tributária dos Municípios. Tudo isto foi amplamente exposto por Souto Maior Borges, no seu clássico "Lei Complementar Tributária"." (in obra citada, 2ª ed., rev. ampl. e atual., Ed. Dialética, São Paulo, 2005, págs. 36/42) A delimitação do conceito de serviço deve se ater aos pressupostos constitucionais.* ***Em termos mais rigorosos, todas características definitórias do definiendum "serviço" estão postas na Constituição Federal. A lei complementar somente pode acrescer características acidentais ou acessórias. Mas não pode estabelecer, como serviço, o que não o é. Por conseqüência, qualquer grandeza eleita para figurar na base de cálculo do ISS que não se origine das características definitórias constitucionais de "serviço" encontra-se estigmatizada pelo vício da inconstitucionalidade." (in obra citada, Organização de Heleno Taveira Tôrres, 1ª Ed., Ed. Manole, São Paulo, 2004, págs.236/237)*** *Deveras, como bem elucida Marcelo Caron Baptista, na obra*

*"ISS: Do Texto à Norma", a exação em tela somente pode incidir se houver a realização de serviço para terceiro, porquanto ser necessária a existência de uma relação "envolvendo, pelo menos, duas pessoas: o realizador e o tomador do serviço". De acordo com o aludido autor, a prestação de serviço, núcleo do critério material da hipótese de incidência do ISS, ostenta natureza jurídica de obrigação de fazer, identificável pelo fim específico a que visa o contrato celebrado entre as partes, a despeito da existência de prestação-meio consistente em um "fazer" ou em um "dar": **"4.1.10. A prestação de serviço como prestação "de fazer"** A hipótese de incidência do ISS, sopesadas as informações colhidas do sistema jurídico, em confronto com a experiência empírica, afasta as prestações negativas de "não fazer" e de "não dar", ainda que, de qualquer modo, caracterizem um fazer em sentido lato, uma ação omissiva. Mesmo que existam várias possibilidades da prestação objeto da relação jurídica identificar-se com um comportamento omissivo, aquele correspondente a "prestar serviço" em benefício de terceiro, mediante remuneração, parece totalmente incompatível com a idéia de uma abstenção. Pelo menos fazemos questão de confessar o fato de não termos vislumbrado sequer uma hipótese nesse sentido. Partindo desse pressuposto, resta analisar, diante das prestações positivas, a distinção entre as de dar e as de fazer. Quanto às típicas prestações de dar e de fazer a explicação não comporta maiores controvérsias. Prestação de dar ocorre quando a ação titularizada pelo devedor se destina à tradição de um bem. Prestação de fazer é aquela que se opera pela ação pessoal do devedor, cuja relevância não está na tradição de bem, ainda que ela possa eventualmente ocorrer. A hipótese de incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou seja, aquelas marcadas pela ação pessoal do devedor. Essa conclusão não se alcança com base na eficácia normativa experimentada por esse tributo ao longo do tempo mas por meio de indicativo colhido da própria Constituição Federal. **A palavra "serviços", constante do artigo 156, III, do Texto, afasta, por incongruência semântica, a idéia de prestação de dar, eis que não envolve, na sua essência, qualquer coisa, seja material, seja imaterial. A ação pessoal do prestador, no entanto, não rejeita o emprego de bens materiais ou imateriais, mercadorias ou produtos industrializados, bem como de equipamentos. Ao contrário, a maior parte dos serviços requer o emprego de tais bens, sob pena de restar inviabilizada a prestação. Mas o comportamento tributado pelo ISS é aquele em que o esforço pessoal do devedor se sobrepõe aos materiais e equipamentos eventualmente aplicados.** Colabora, também, nesse sentido, o confronto de "serviços" com a materialidade de outros tributos, especialmente o ICMS -no quanto se refere a operações relativas à circulação de mercadorias -e o **IPI** - exceto sobre importação de produtos. Ainda que o critério material destes últimos não se resuma a uma prestação de dar, porque sua essência está na realização de operações jurídicas, elas, invariavelmente, giram em torno de um bem material, de uma mercadoria ou de um produto industrializado, o que não ocorre com o ISS. Este tributo, portanto, é dirigido preponderantemente à*

*atividade pessoal do sujeito passivo da relação jurídica patrimonial. O tomador do serviço, quando o contrata, objetiva não a apropriação de um bem mas o resultado do esforço e da capacidade, física ou intelectual, da outra parte, ainda que esse resultado se expresse, no mundo fenomênico, por meio de um bem material. Prestação de serviço, por isso, é prestação jurídica de fazer. " **4.1.11 Prestação-meio e prestação-fim** Como desdobramento da distinção fundamental entre prestações de dar e de fazer, surge a necessidade de admitir que um esforço humano, no contexto de uma relação jurídica contratual, não assegura ao intérprete, por si só, tratar-se de uma prestação de fazer, e ainda tributável pelo ISS. Muitas vezes a complexidade dos fatos jurídicos torna deveras difícil estabelecer os contornos precisos que permitem apartar, das prestações em geral, as figuras do dar e do fazer, o que acarreta importantes reflexos para a compreensão da norma tributária, ocasionando, em algumas vezes, dúvidas razoáveis sobre a incidência de determinados tributos diante de específicas hipóteses. A presença do contrato é mais do que o primeiro divisor de águas para limitar o conjunto de comportamentos passíveis de tributação pelo ISS. É dele que aflora a natureza jurídica tributária da prestação. Centra-se a investigação, por isso, no acordo de vontades. As relações jurídicas são estabelecidas em torno de uma prestação que, quando adimplida, extingue o dever jurídico do sujeito passivo. Todo contrato visa a um fim específico. É um dos meios pelos quais o homem busca a satisfação de suas necessidades, relacionando-se com terceiros. Exatamente da finalidade do contrato é que se extrai a natureza da prestação. Imprescindível estabelecer, pois, um critério jurídico pelo qual seja possível identificar o **comportamento-fim pactuado** , aquele que, ocorrido, faz extinguir o dever jurídico. As lições da doutrina são precisas sobre o tema. Para ORLANDO GOMES "a distinção entre as obrigações de dar e as de fazer deve ser traçada em vista do interesse do credor (...). Nas obrigações de dar, o que interessa ao credor é a coisa que lhe deve ser entregue, pouco lhe importando a atividade do devedor para realizar a entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do serviço contratado" . O interesse do credor, portanto, pode estar voltado, preponderantemente, para um bem ou para um comportamento do devedor. No primeiro caso, a prestação a que faz jus o credor é a de dar; na segunda, a de fazer. Entre o seu surgimento e a sua extinção, a relação -colocado à parte o direito à remuneração -fica na dependência do comportamento-fim imputado ao devedor. Tal comportamento pode ser um ato simples, unitário, facilmente identificado; ou pode ser complexo, caso em que requer a observância de etapas, para que o fim contratado seja atingido. (...) Em outras palavras, serviço faz-se, não se dá. Em suma: nas obrigações ad dandum ou ad tradendum consiste a prestação em entregar alguma coisa (dar), enquanto que as infaciendo se referem a ato ou serviço a cargo do devedor (prestador). (...) **Franquia: Utiliza-se o termo franquia ou franchising. O vocábulo franchising provém do inglês franch, que teve origem no francês medieval franc, surgindo francher, no***

sentido de outorga de privilégio, uma forma de autorização ou abandono de servidão. Franchising, do verbo to franch, constitui um instrumento destinado a fomentar processos de venda e distribuição em série, com características específicas.(...) *No Brasil, segundo Rubens Requião (1978:43), o contrato examinado apareceu sob a forma de concessão mercantil, como no técnica de distribuição de filmes cinematográficos das grandes empresas que detinham a marca dos conceituados estúdios norte-americanos, passando a ser posteriormente utilizado pela indústria. As empresas importadoras de veículos também começaram a utilizar o instituto, mediante concessão exclusiva, para a distribuição dos veículos importados que ingressaram em nosso país. (...)* ***O contrato de franquia envolve cessão de marca, transferência de tecnologia, assistência técnica. É um conjunto de fatores e não prestação de serviços. Esta, quando existente, é indissociável dos outros fatores. O franqueado não presta serviços ao franqueador ou vice-versa. Franquia não é serviço. É cessão de direitos. A supervisão de rede, orientação, treinamento do franqueado e de seus funcionários, escolha de ponto é obrigação de meio para a realização da franquia e não serviço . A lei tributária não pode estabelecer um conceito diverso do previsto no Direito Comercial (art. 110, do CTN) para alterar a definição do instituto e considerá-lo como serviço, que não é. (...) A franquia é um contrato complexo. Não é exatamente serviço. (...)" (In obra citada, 7ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2006, págs. 272/278)*** *Aires F. Barreto bem elucida a natureza jurídica do contrato de franquia, verbis: "A franquia é materializada por contrato de cunho mercantil que resulta do acordo de vontades entre o titular da marca (designado concedente ou franqueador) e o cessionário desses direitos de uso de marca, intitulado franqueado. Para atingir o fim do contrato, consubstanciado no direito de uso dos produtos ou serviços representados pela marca, o franqueado ou franqueador assumem deveres heterogêneos -gerados para ambas as partes -visando à consecução do contrato, qual seja, o direito de uso dos produtos ou serviços representados pela marca. O conteúdo do contrato de franquia envolve obrigações de dar, de fazer e de não-fazer. Disso decorre a complexidade do contrato de franquia e a inexorável impossibilidade de dissociação dos diversos elementos do contrato, para fins de consideração jurídica . (...) Não é possível seccionar o contrato de franquia em vários outros, para considerá-lo de per si. O contrato de franquia é contrato misto, complexo, indivisível. Não se confunde com contratos coligados . Como ensina Orlando Gomes, quando há contratos coligados, existe duplicidade contratual, cada qual com causa própria. A união dos contratos, muito embora consustanciam-se num mesmo instrumento, concluindo-se num mesmo átimo, é exógena ou externa. Cada qual mantêm individualidades e autonomias próprias. Não há que se cogitar de fusão, isto é, embora ocorra a acumulação, não se tem por resultado um contrato unitário. Na estruturação e na eficácia, distinguem-se os contratos coligados dos contratos mistos. A coligação dos contratos não acarreta a perda da individualidade dos contratos, ao contrário do misto. Na coligação, os*

*contratos são autônomos, mas se ajustam, unem-se em relação de união com dependência, de união alternativa ou união meramente exterior. (...) A seu turno, nos contratos mistos, dentre suas subsespécies, destacam-se os contratos complexos, em que as diversas prestações correspondem várias contraprestações. No contrato coligado, cada figura contratual apresenta autonomia funcional, mesmo naquela hipótese onde um dos contratos não possa existir autonomamente. Já no contrato complexo (misto), há uma unidade de causa, uma função jurídica específica, que somente é preenchida pela conjugação de diversas cláusulas e condições. É o que se verifica irretorquivelmente no contrato de franquia. (...)**Em suma, a franquia é um contrato misto, do tipo complexo. Ao franqueador incumbe, fundamentalmente, conceder licença para o uso da marca. A essa obrigação se conjugam elementos: contratos completos, prestações típicas inteiras, ou elementos mais simples de outros contratos. Tem-se aí uma unidade contratual. Não há como separar esses diversos elementos porque, absorvidos, fundidos, amalgamados no contrato de franquia, perdem totalmente sua individualidade, deixando de ser autônomos. Dentre eles, despontam as atividades necessárias à consecução da franquia, sob pena de desnaturação do contrato .**" (In "ISS na Constituição e na Lei", 2ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2005, págs. 210/213) Arremata o insigne tributarista que "é inequívoca a intributabilidade, por via de ISS, da atividade de franquia", uma vez que "o franchising (espécie de cessão de direitos) não se subsume ao conceito constitucional de serviços tributáveis por esse imposto municipal; conseqüentemente, dita atividade econômica não está abrangida pela competência tributária atribuída aos Municípios pela Constituição Federal", o que torna inarredável a ofensa ao texto constitucional pelo Subitem 17.08 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 (In obra citada, pág. 219). **Forçoso relembrar que, consoante o voto que se sagrou vencedor no Plenário da Excelsa Corte (RE 116121/SP), "há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento".** A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto, composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço (obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios. As proposições acima conduzem à inequívoca inconstitucionalidade do subitem 17.08, da relação anexa à Lei Complementar 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre a franquia, por isso que se conjura a incompetência imediata do STJ para a análise de recurso que contenha essa antinomia como essência em face da repartição constitucional que fixa os lindes entre esta E. Corte e a Corte Suprema. Deveras, a mesma competência foi exercida pela Corte Suprema na análise prejudicial dos*

conceitos de faturamento e administradores e autônomos para os fins de aferir hipóteses de incidência, mercê de a discussão travar-se em torno da legislação infraconstitucional que contemplava esses conceitos, reproduzindo os que constavam do texto maior. Aliás não é por outra razão que o CPC dispõe no artigo 543 que: "Art. 543. Admitidos ambos os recursos, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. (...) § 2º Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial àquele, em decisão irrecorrível sobrestará o seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do recurso extraordinário. (...)" Sobressai, desta sorte, imprescindível a manifestação da Corte Suprema sobre o thema iudicandum, suscitado de forma explícita ou implícita em todas as causas que versam sobre a competência tributária municipal, essência manifesta das decisões que tem acudido ao E. STJ. Assim, as conclusões e premissas de índole notadamente constitucional, sem as quais não sobreviveria o aresto recorrido, impõem timbrar seu fundamento constitucional para, na forma da jurisprudência cediça na Corte, não conhecer do recurso especial. (...) Outrossim, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 10, segundo a qual: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte". Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC." Destarte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão ora hostilizada, razão pela qual merece a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos. Ex positis , NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental".

Trata-se por certo as jurisprudências acima colacionadas, de casos análogos, já que tratam de ISS, todavia servem como propósito para definição do conceito que se aplica pelo STJ aos contratos de franquia, inclusive o de franquia postal.

Este fato, é mais um ponto contundente na apuração de que o legislador, sabendo que, um contrato de franquia **tem causa e conteúdo próprio**, conforme amplamente entendem os Ministros do Tribunal Superior, tratando a atividade desempenhada pelo franqueado como de distribuidor inadmissível entender que exista a concessão, bem como, que exista a permissão, pois visam licitar contratos provenientes de uma natureza distinta, da que se encontra no contrato de franquia postal, que em hipótese alguma se iguala a contrato de prestação de serviços.

A condição de se tornar um contrato de franquia, proveniente de um ato administrativo, não transforma sua natureza, como

bem definiu o STJ, e nem poderia, tampouco tinha o legislador esta intenção quando do advento da Lei 11.668/2008, pois fez com que a Lei de Franquia Postal ficasse subsidiada a Lei do Franchising.

Desta forma, seja um contrato de franquia de fast food, seja um contrato de franquia de Postal, ambos mantém sua natureza própria.

Ainda importante estabelecer que o serviço postal foi considerado pela Excelsa Corte como sendo um serviço publico, todavia quem presta o serviço público é a ECT e não o franqueado.

Assim reza a regra do art. 7° da Lei 6.538/1978:

"DO SERVIÇO POSTAL

Art. 7º - Constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, conforme definido em regulamento".

Assim define o art. 2° da mesma Lei:

"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações".

As franquias postais apenas realizam atividade auxiliar, intermediária, não podendo exercer atividade de recebimento, expedição, transporte e entrega.

Ao alterar a Lei 11.668/2008, o Decreto 6.639/2008 também violou direitos fundamentais, conforme adiante se comprovará.

VIII) DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Quando o decreto, ora impugnado alterou a Lei 11.668/2008, também violou direitos fundamentais previstos em nossa Constituição.

Como aplicação máxima do conceito de legislar tem-se que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, tampouco o ato jurídico

perfeito e de fato a Lei 11.668/2008, não violava a nenhum direito fundamental, todavia, o Decreto que tinha por objetivo sua regulamentação viola num mesmo momento vários princípios e direitos fundamentais.

Assim determina a regra contida no inc. XXXVI do art. 5° de nossa Constituição:

> ***"XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;".***

Conforme a lição do ilustre professor Kildare Gonçalves Carvalho, tem-se que:

> "***Tem-se por direito adquirido, segundo estabelece o art. 6°,§ 2°, da Lei de Introdução do Código Civil, aquele que o seu titular ou alguém que por ele possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixado, ou condição preestabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. Pontes de Miranda, ao tratar do dificílimo tema, define o direito adquirido como "o direito irradiado de fato jurídico, quando a lei não o concebeu como atingível pela lei nova"".***(DIREITO CONSTITUCIONAL, ED. DEL REY, CARVALHO, KILDARE GONÇALVES, 14 ED., PG 746).

Clóvis Beviláqua dá ao direito adquirido o seguinte conceito:

> *"Os direitos adquiridos, que as leis devem respeitar, são vantagens individuais, ainda que ligadas ao exercício de funções públicas".* (TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL, BEVILÁQUA, CLÓVIS, PG 19).

Quanto ao ato jurídico perfeito tem-se que:

> *"Ato jurídico perfeito, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil (art. 6°, §1°), é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Pontes de Miranda sustenta que ato jurídico perfeito "é o negócio jurídico, ou o ato jurídico stricto sensu; portanto, assim as declarações unilaterais de vontade, como os negócios jurídicos bilaterais, assim os negócios jurídicos, como as reclamações, interpelações,*

a fixação de prazo para a aceitação de doação, as comissões...

Portanto, é perfeito o ato jurídico que reúna os elementos substanciais previstos na lei civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada por lei. Ressalte-se ainda que, embora não consumado, o ato jurídico perfeito que se encontra apto a produzir efeitos tem garantia a sua execução contra a lei nova que não os pode regular, subordinados que ficam à lei antiga".

Importante aqui fazer uma breve análise e apontamento ao contrato de franquia ao qual a Lei 11.668/2008 pretende regulamentar.

Em primeiro lugar que se trata de um contrato revestido de legalidade, visto que submetido está à mesma lei anterior que os orienta na lei atual, qual seja, a regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978.

Em segundo lugar, por preencher os requisitos de um ato jurídico perfeito, jamais poderia ser extinto em face da regra contida nos parágrafos do art. 9° do Decreto 6.639/2008.

Quando o Decreto 6.639/2008 no inc. I do §3° do art. 2° cria uma nova denominação que não estava prevista na Lei, determinando que esta nova unidade de franquia – AGF - então criada, fosse licitada e no art. 9° §§ 1° e 2° determina a extinção dos contratos em plena vigência desrespeita o direito adquirido de mais de 1400 franqueados, bem como, manda extinguir um ato jurídico perfeito que na maioria dos casos trata-se de relação jurídica existente há mais de 17 anos.

Em momento algum, as partes contratantes, franqueado e franqueador, demonstraram o animo de extinguir tal relação jurídica, senão em face da determinação inconstitucional da regra contida no art. 9° e seus parágrafos do decreto ora impugnado.

Vejam, Eméritos Ministros, não se pode extinguir uma relação jurídica, um ato jurídico perfeito, sem o consentimento das partes ou ainda qualquer ânimo que justificasse tal conduta.

Não bastasse a inexistência de previsão na Lei 11.668/2008, que apenas tinha por objetivo a regularização e manutenção dos contratos de franquia, quiçá, através de uma alteração advinda de um

Decreto, cuja característica e natureza é dar condições para a possibilidade de se cumprir a lei.

Via de regra, tal norma – inc. I §3° art. 2° e art. 9° §§ 1° e 2° -, ao extinguir unilateralmente e de forma arbitrária uma relação jurídica, que se trata de um ato jurídico perfeito e do direito adquirido fere ainda o inc. XIII do art. 5° da Constituição, quando cria uma nova modalidade - AGF, ou seja: **o direito à livre iniciativa e o princípio do livre exercício do trabalho.**

Isto porque simplesmente extingue com uma classe inteira, consistente em mais de 17 anos de dedicação, inibindo que continuem exercendo sua atividade laboral alheio à vontade de ambas as partes que mantém a relação jurídica.

Não obstante viola o **principio da legalidade**, quando transpõe sua função de poder regulamentador, alterando o ato normativo da Lei 11.668/2008, inc. I §3° do art. 2°, tornando-a inconstitucional em decorrência da violação de direitos e princípios fundamentais.

Quando viola o **principio da igualdade**, art. 4° e 5° do Decreto 6.639/2008, o faz porque deixa de estabelecer critérios compatíveis com o que a Lei exigia e ainda deixa de trazer equilíbrio para dentro da formalidade rígida que exige o ato administrativo, extrapolando sua função e obrigando à Administração Pública a extrapolar o poder discricionário que lhe cabe.

Em decorrência da violação do principio supracitado, existe a observância da **dupla crise**, ou seja, ora não há proposta alguma, ora não há concorrente, ou seja, apenas os licitantes que nada mais são do que aqueles que já existiam e, por fim, em alguns casos existe um ou outro concorrente como no caso do edital n. 3508/2009 - PR em que o concorrente era uma empresa individual cuja atividade mercantil era a de prestação de **serviços odontológicos**.

É possível assim verificar que não se preenche os pressupostos necessários para que seja satisfeita a presente licitação, pois não existe meio que permita a aplicação adequada de nossa legislação, sem criar desequilíbrio para as partes que concorrem ao edital como proposto pelo decreto.

Ainda quando o Prof. Marçal Justen Filho faz menção a tais pressupostos tem-se que:

> ***"Na primeira categoria, encontram-se os casos de inviabilidade de competição por ausência de pluralidade de sujeitos em condições de contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a natureza do objeto, eis que a inviabilidade de competição não decorre diretamente disso. Não é possível a competição porque existe um único sujeito para ser contratado.***
>
> ***Na segunda categoria, podem existir diversos sujeitos desempenhando a atividades que satisfaz a necessidade estatal. O problema da inviabilidade de competição, não é de natureza numérica, mas se relaciona com a natureza da atividade a ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à própria profissão desempenhada. Não é viável a competição porque características do objeto funcionam como causas impeditivas".*** (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 357/358).

Assim é possível entender que fica evidente a ausência de mercado concorrencial, tanto é verdade que a própria requerida, retira do edital a questão referente à qualificação técnica e conforme consta em sua própria resposta à impugnação administrativa, deixa evidente que, se exigisse tal qualificação **tornaria a concorrência inviável**.

Assim se manifesta a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando da resposta à impugnação administrativa:

> *"Quanto à exigência de experiência (capacidade técnica),* ***embora prevista em lei,*** *decorre antes de tudo* ***do poder do exercício discricionário que é conferido ao administrador público****, o qual* ***optará pela solução que melhor satisfaça a conveniência e oportunidades públicas****. A exigência do ACT deve ser justificada (motivada)* ***a sua real necessidade uma vez que a utilização aleatória poderá vir a cercear a competição***

> ***no certame***, *in correndo na vedação prevista no art. 3°, §1°, da Lei 8.666/1993". Sobre o assunto já se pronunciou o TCU, ao dispor que, in verbis, pode-se concluir que a entidade que promove a licitação deve* ***fundamentar adequadamente a exigência da capacidade técnica***, *demonstrando de forma* ***inequívoca*** *sua* ***imprescindibilidade e pertinência*** *em relação ao objeto licitado....Na hipótese, tal exigência não se mostra viável, porquanto* ***restringiria o universo de interessados*** *no certame,* ***apenas aos atuais franqueados****".***(RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DATADA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010, PG. 02, CARTA 0063/2010, CEL 001/2009/DR/PR).

Veja Emérito Ministro, apenas com esta resposta a própria ECT define que se cabe ao Administrador Público o poder de não respeitar a lei, a ponto de deixar de cumprir um pressuposto tão importante, ainda mais por se tratar da modalidade de concorrência, qual seja, a habilitação e capacidade técnica, por qual motivo esta respeitando a lei de franquia postal, cujos vícios são aparentes e ainda pende de várias discussões inclusive acerca de sua inconstitucionalidade decorrente do decreto.

A justificativa que a ECT ousa, acerca do poder discricionário que lhe serve nada mais é do que, eu posso e quero desrespeitar a regra contida no art. 27, inc. II da Lei 8.666/1993, para respeitar a regra contida no art. 2° do Decreto 6.639/2008, todavia ao avaliar desta forma, a Administração Pública, no caso a ECT viola e fere outras normas e princípios rígidos constitucionais.

Outrossim, a própria ECT com a resposta acima transcrita, aceita o fato de que nenhuma outra empresa poderia concorrer com franquias de correio já existentes, aceitando também o fato de que se trata de um **serviço essencial e que necessita de especialidade**, caso contrário qualquer um estaria habilitado, não precisando de treinamento.

Por fim, a ECT em momento algum comprova de forma inequívoca a desnecessidade de comprovação da habilitação e capacitação técnica, até porque se trata de um serviço essencial público, cujo treinamento não poderia ser inferior a seis meses, afora acompanhamento intenso de auditores e fiscais, não sendo possível qualquer empresa

participar do certame e ser considerada apta a prestar um serviço de tamanha importância em apenas duas semanas.

Apoiar esta idéia seria o mesmo que fadar, o nosso orgulho postal, ao insucesso, e daí sim, colocá-los novamente nas mãos de empresas privadas.

No que tange a ausência de mercado concorrencial e de objetividade na seleção do objeto Marçal Justen Filho tem o seguinte posicionamento:

> *"Outra hipótese consiste nas características do mercado privado envolvendo o tipo de prestação pretendida pela Administração Pública. Embora possam existir diferentes alternativas para satisfação do interesse sob tutela estatal, não se configura um mercado na acepção de conjunto de fornecedores em disputa permanente pela contratação a qualquer tempo, eis que os particulares em condições de executar a prestação não competem entre si formulando propostas. Esses particulares aguardam propostas de possíveis interessados, não estabelecendo diferença mesmo em relação ao setor público.* ***Ou seja, configura-se um mercado peculiar, eis que não existe a dimensão concorrencial encontrada no âmbito de compras, obras e outros serviços. Daí a referência à inexistência de um mercado concorrencial.***
>
> *A hipótese imediatamente considerada acima, também se caracteriza, como regra, pela impossibilidade de seleção segundo critérios objetivos. Existem diferentes alternativas, mas a natureza personalíssima da atuação do particular impede julgamento objetivo, é impossível definir com precisão uma relação custo benefício, Ainda que seja possível determinar o custo,* ***os benefícios que serão usufruídos pela Administração são relativamente imponderáveis.***
>
> *Essa incerteza deriva basicamente da natureza subjetiva da avaliação, eis que a natureza da prestação envolve fatores intelectuais, artísticos, criativos e assim por diante. Não há critério objetivo de julgamento, a*

competição perde sentido. (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 357/358)".

Ora, por certo que a requerida ao responder a impugnação administrativa desta forma: "*Quanto à exigência de experiência (capacidade técnica), **embora prevista em lei,** decorre antes de tudo **do poder do exercício discricionário que é conferido ao administrador público**, o qual **optará pela solução que melhor satisfaça a conveniência e oportunidades públicas"***, deixou claro que neste caso pelo menos em momento algum optou pela melhor solução.

Pois se o preço já estava fixado no edital, ou seja, EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA, MELHOR PROPOSTA TECNICA, COM PREÇO FIXADO NO EDITAL, a requerida não corria o risco de contratar pelo maior preço, todavia optou em possibilitar que qualquer um participasse da licitação correndo o risco de ter um serviço público essencial mal executado.

E ainda, para aqueles que não tem experiência ainda terá que dispor do dinheiro da Administração Pública para fornecer treinamentos, consultorias, dentre outras questões que por certo serão geradas, onerando os cofres da requerida.

Tem-se então a teoria da efetivação da melhor contratação, qual seja, se existe um preço que já esta pré-fixado, a Administração Pública tem que por obrigação, perseguir a melhor contratação, ou seja, contratar aquele que melhor esteja qualificado tecnicamente para executar o objeto do contrato.

Por tais motivos, é que se faz necessário esta ADI, cuja finalidade é a proteção do bem maior fincado em nossa Constituição Federal, os seja, os preceitos fundamentais.

IX) CONCLUSÃO

A Lei 11.668/2008 não poderia alterar a natureza jurídica do contrato de franquia postal, que tem causa e conteúdo próprio, e nem tinha por objetivo alterá-la, prova deste fato é que o legislador submeteu-a

à regra contida no art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, cuja mesma recepcionava exceções e não à regra do art. 175 da Constituição Federal.

Assim fez o legislador porque comungava da mesma idéia pacificada em nossa jurisprudência e doutrina acerca da não aplicabilidade, aos contratos de franquia, da natureza jurídica aplicada aos contratos de prestação de serviços, bem como, por entender que a teoria geral dos contratos se aplica também aos contratos administrativos, sobrepondo assim as regras eventualmente originadas da relação entre a Administração Pública e a pessoa jurídica de direito privado.

O legislador entendeu tratar-se de uma atividade essencial para a sociedade, reconhecendo sua especialidade, motivo que o levou a manter num primeiro momento os contratos existentes e expandi-los num segundo momento levando-se em conta a necessidade de regularizá-los e de melhorar o serviço postal – art. 6°, inc. III e IV da Lei 11.668/2008.

O Ato normativo impugnado extrapolou sua função de ato regulamentador, contrariando a regra contida no art. 6° e 7° da Lei 11.668/2008, criando um novo modelo de franquia – AGF – sem qualquer base ou estudo de viabilidade.

Em decorrência da criação de um novo modelo, foi necessário extinguir a relação jurídica anterior, os contratos anteriores o modelo de franquia existente até então – ACF -, sem qualquer fundamento consistente e amparo legal.

Para tanto, não poderia ser diferente, atropelou preceitos fundamentais como, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o principio da legalidade, o principio da igualdade, o principio do direito à livre iniciativa e o princípio do livre exercício do trabalho, afora princípios provenientes da teoria geral dos contratos.

Sendo assim, *data máxima vênia*, necessário que esta Excelsa Corte, na condição que lhe cabe de Guardião da Justiça, que se encontra em seu mais alto grau, tecida em nossa Carta Magna, afaste as violações acima citadas resguardando assim os preceitos fundamentais desrespeitados e garantindo a soberania do bom direito.

X) DO PEDIDO

Ante o exposto,

em face dos argumentos supramencionados:

01) Preliminarmente, requer seja julgado procedente o pedido referente ao reconhecimento da legitimidade ativa da autora para propor a presente ADI, conforme fundamentos supramencionados, tendo em vista a natureza do objeto jurídico aqui tutelado, os preceitos fundamentais que se entendem como sendo de maior relevância norteados pela regra contida no art. 5°, incisos XVII, XVIII, LIV e art. 174 §2° da Constituição Federal;

02) Liminarmente, requer seja deferido o pedido em caráter cautelar, com efeito *ex tunc*, conforme sustentado no item V da presente peça, **determinando a suspensão** do efeito contido na norma ora impugnada, qual seja, o inc. I, §3° do artigo 2°, artigo 4° e artigo 5° do Decreto 6.639/2008, em razão da impossibilidade de se licitar da forma como proposto, afora o fato de se estar propondo um modelo não previsto na legislação – AGF, bem como, **a suspensão** da eficácia da norma contida no art. 9° §§ 1° e 2° do Decreto 6.639/2008, considerando a presença do *"fumus boni iuris"* e do *"pericilun in mora"*, confirmado através da verossimilhança das alegações, conforme os fundamentos de fato e de direito supracitados;

03) No mesmo sentido, requer seja deferida cautelar, a fim de que as licitações em todo o país sejam suspensas, ou caso esta Excelsa Corte não entenda que assim seja possível, que pelo menos, num primeiro momento, os editais de licitação dos associados sejam suspensos, quais sejam EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE **AGENCIAS DE CORREIOS FRANQUEADAS - AGF** POR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, SOB O REGIME DE FRANQUIA POSTAL, 3501/2009; 3507/2009; 3508/2009; 3509/2009; 3510/2009; 3511/2009; 3516/2009; 3522/2009; 3523/2009; 3525/2009; 3529/2009; 3531/2009; 3532/2009; 3533/2009;

04) Em decorrência do deferimento do preceito, seja cominado desde já uma multa penal dia significativa a ser arbitrada pelo Emérito Ministro fixando desde já o prazo para cumprimento do mesmo, conforme regra contida no art. 461§ 5.º e seguintes do CPC, em caso de descumprimento do preceito por parte da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

05) Requer ao final seja confirmado o pedido em caráter cautelar;

06) Requer seja julgado procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de que seja impugnado as regras contidas no inc. I, §3° do artigo 2°, artigo 4°, artigo 5° e art. 9° §§ 1° e 2° do Decreto 6.639/2008 entendidas como inconstitucionais, infratoras de princípios e direitos fundamentais;

07) Requer seja deferido todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive oportunizando desde já o direito à sustentação oral conforme disposto pelo §2° do art. 10° da Lei 9.868/1999;

08) Requer seja oficiado a todos os Tribunais Regionais Federais, caso seja este o entendimento desta Excelsa Corte a fim de apurar a veracidade das informações acerca do numero de ações em trâmite, bem como, do número de editais suspensos, aplicando de forma análoga a regra contida no artigo 9°, §2° da Lei 9.868/1999;

09) Requer seja cumprido o que determina a regra contida no artigo 6° da Lei 9.868/1999, a fim de que sejam prestadas as informações necessárias;

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Curitiba, 26 de julho de 2010.

Marcelo Arthur Menegassi Fernandes	***Ane Gonçalves de Resende Fernandes***
OAB/PR 31.367	***OAB/PR 31.337***